

1500622-05.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500622-05.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071460/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 16761301 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 984/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2071460 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 984/2021 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONAM PAULO MATHIAS DA SILVA

Data da Audiência:

08/03/2022

Em 8 de março de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho

Soffner. Presente o réu Leonam Paulo Mathias da Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Rodrigo Alberto da Silva e Maxwell Ramos dos Santos. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LEONAM PAULO MATHIAS DA SILVA, qualificado às fls. 8 e 12, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de março de 2021, por volta de 10h:39min, na Rua Lourival Portal da Silva, nº 59, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, transportava, para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, visando o tráfico, 21 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 20,11 gramas de cocaína (Item 1); 47 invólucros plásticos contendo 135,34 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 2); 41 invólucros plásticos contendo 11,32 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3); e 30 frascos de lança-perfume contendo 3 mililitros de Tricloroetileno, substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação de fls. 21/23 e laudos toxicológicos de fls. 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130 (fls. 135/136). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 45/46). A denúncia foi oferecida (fls. 134). O réu foi notificado (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 151/152). A denúncia foi recebida e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 153/158). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Rodrigo Alberto da Silva (gravação audiovisual) e Maxwell Ramos dos Santos (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Leonam Paulo Mathias da Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Alberto da Silva (fls. 5) e Maxwell Ramos dos Santos (fls. 6) e o réu Leonam Paulo Mathias da Silva (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Leonam, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 15/16). Laudo de constatação provisória (fls. 21/23 = 110/112 e 95/96 = 116/117). Auto de entrega (fls. 75). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 176/177). Folha de antecedentes (fls. 138/139) e certidão (fls. 29). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de

prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 21/23 = 110/112 e 95/96 = 116/117), auto de entrega (fls. 75), exame químico toxicológico definitivo (fls. 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130), laudo de exame de corpo de delito (fls. 176/177) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Rodrigo Alberto da Silva disse que: a) me lembro da ocorrência; b) estava em patrulhamento pelo Zaira e havia uma denúncia, de que um indivíduo estaria sentado na cadeira, ao lado de um veículo Sandero, e ele estaria portando uma arma de fogo; c) fomos ao local e o réu estava sentado ao lado de um veículo Sandero, mas com ele não foi encontrado arma; d) perguntamos de quem era o veículo e o réu disse que era dele; e) as drogas estavam dentro de uma bolsa preta e eram variadas; f) as drogas eram maconha, cocaína e acho que um pouco de lança-perfume, não me lembro a quantidade, mas não era pouca; g) eu não conhecia ele não; h) ele morava próximo ao local, naquela rua, a mulher dele até pareceu lá; i) o local era conhecido como sendo ponto de venda de drogas (gravação audiovisual e fls. 5). A testemunha Maxwell Ramos dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência; b) fomos acionados via COPON de que um indivíduo em um Sandero prata portava arma de fogo; c) em patrulhamento, encontramos o indivíduo ao lado do Sandero prata e em revista pessoal nada foi encontrado; d) ele disse que o veículo era dele e ele estava com as chaves do veículo; e) dentro do veículo havia uma bolsa feminina, que haviam algumas drogas; f) ele disse que não sabia de quem eram as drogas; g) não me lembro as quantidades, mas havia maconha e cocaína; h) não conhecia o réu; i) eu não me recordo se ele estava sentando ou em pé, ele estava fora do veículo (gravação audiovisual e fls. 6). Por fim, o réu Leonam Paulo Mathias da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) as drogas foram encontradas no meu carro, um Renan Sandero branco; b) as drogas não eram minhas; c) as drogas eram de um moça, que a chamam por "Nega"; d) eu não sabia que as drogas estavam no meu carro; e) eu estava distante do carro, comendo lanche com o meu irmão no dia; f) eu não tenho certeza de que as drogas foram colocadas pela "Nega", mas era ela que estava no dia traficando e a bolsa estava com ela; g) eu não conversei com a "Nega" no dia; h) na hora em que a viatura chegou as chaves do veículo estavam comigo, mas não sei se ele estava fechada ou não; i) a Rua Lourival Portal da Silva é sem saída e no final há uma bica d'água; j) não sei se ela vira Jesuino dos Santos (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 21/23 = 110/112 e 95/96 = 116/117), auto de entrega (fls. 75), exame químico toxicológico definitivo (fls. 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130), laudo de exame de corpo de delito (fls. 176/177), como também pelos depoimentos das testemunhas Rodrigo Alberto da Silva (gravação audiovisual e fls. 5) e Maxwell Ramos dos Santos (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM para verificação de denúncia de indivíduo que estaria portando uma arma de fogo, em um veículo Renault Sandero, placas FNI-7344. Ao chegarem ao local e localizarem o veículo Sandero, encontraram o réu Leonam, que foi revistado e nada foi localizado com ele. Contudo, o réu disse ser o proprietário do veículo Sandero, ele tinha as chaves do veículo e dentro dele, no assoalho direito do veículo, foram localizados 21 eppendorfs de cocaína, pesando 20,11g, 47 porções de maconha, pesando 135,34g, 41 porções de crack, pesando 11,32g, e 30 frascos de lança-perfume contendo 3ml, dentro de uma bolsa preta. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação

para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Inclusive, o réu diz que não conversou com a tal traficante "Nega", no dia dos fatos (gravação audiovisual), mas, extrajudicialmente, ele disse ter emprestado as chaves do veículo Sandero para ela (fls. 7), ou seja, a sua autodefesa sequer merece credibilidade, pois não se equivalem nas fases procedimentais. Portanto, pelas

provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Leonam Paulo Mathias da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (20,11g, 47 porções de maconha, pesando 135,34g, 41 porções de crack, pesando 11,32g, e 30 frascos de lança-perfume contendo 3ml - fls. 15/16, 21/23 = 110/112, 95/96 = 116/117, 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29 e 128/139). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por não haver outro parâmetro de redução, entre 1/6 e 2/3, contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3. Inclusive, no processo nº 1500527-09.2020.8.26.0540, que tramita nesta Vara (fls. 318/325), foi determinado que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 29 e 128/139), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (135,34g, 41 porções de crack, pesando 11,32g, e 30 frascos de lança-perfume contendo 3ml - fls. 15/16, 21/23 = 110/112, 95/96 = 116/117, 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O

acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempe pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando

diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (135,34g, 41 porções de crack, pesando 11,32g, e 30 frascos de lança-perfume contendo 3ml - fls. 15/16, 21/23 = 110/112, 95/96 = 116/117, 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 9/10). Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 15/16, 21/23 = 110/112, 95/96 = 116/117, 86/88 = 97/100 = 101/103 = 113/115 = 118/121 e 128/130). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LEONAM PAULO MATHIAS DA SILVA (R.G. nº 42.075.809 - filho de Manoel Vieira da Silva e Rosângela dos Santos Mathias - fls. 8 e 12), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 45/46). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; d) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.